

1500690-35.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500690-35.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127491/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 24885479 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2127491 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL ESTANISLAU DE SOUZA SILVA JUNIOR

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 11 dias do mês de agosto de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). André Luiz da Silva Araujo. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) ISRAEL ESTANISLAU DE SOUZA SILVA JÚNIOR, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Eduardo de Carvalho Oliveira, Leandro Souza Duarte.

Ausente a testemunha arrolada em comum pelas partes: Joseanderson Almeida César Júnior, o qual foi devidamente intimado, mas não compareceu nem virtual e nem pessoalmente.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito

cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) comuns (Eduardo, Leandro) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Joseandresson.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Joseandresson Almeida César Júnior.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, ISRAEL ESTANISLAU DESOUSA SILVA JUNIOR está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS, com indicação de provas da autoria e materialidade delitivas:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2022, por volta de 03h00min, na Rua das Sapucaias, altura do n. 236, Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, ISRAEL ESTANISLAU DE SOUZA SILVA JUNIOR, qualificado e indiciado às fls. 06/07, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos com o adolescente Joseandresson Almeida Cesar Junior, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 53(cinquenta e três) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 10,6g(dez gramas e seis decigramas), e 33 (trinta e três) invólucros contendo "crack", substância derivada da cocaína, com peso líquido de 3,3g (três gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, surpreenderam o adolescente na posse de uma pochete e viram que ele, ao perceber a viatura, empreendeu fuga para uma mata. Após perseguição, detiveram-no e apreenderam em poder dele as drogas acima descritas, dinheiro (R\$66,00) e um rádio comunicador.

Nas proximidades, por outra viatura, foi detido o denunciado, o qual portava um rádio comunicador idêntico ao apreendido com o menor. Aos policiais, o denunciado confessou que exercia a função de olheiro, avisando o adolescente sobre a aproximação de viaturas policiais.

O menor também confirmou aos milicianos a prática do comércio de drogas e que recebia informações do denunciado.

Assim, é certo que ambos, agindo de comum acordo, realizavam, com funções distintas, o tráfico ilícito de entorpecentes.

Na delegacia, o denunciado e o adolescente ficaram em silêncio.

Auto de exibição e apreensão de fls. 15-16, laudo de exame de constatação provisória de fls. 20-22 e laudo de fls. 76-78.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

EDUARDO DE CARVALHO OLIVEIRA - Policial Militar - narrou que estava em patrulhamento e viu o adolescente Josanderson. Ele vinha subindo a rua e correu para o mato assim que viu a viatura. Ele carregava algo consigo, em ambas as mãos. Ele carregava uma pochete e um rádio comunicador. Depois de o réu ser abordado e colocado na viatura, deparou-se com outra viatura abordando o réu ISRAEL. Este também tinha um rádio transmissor idêntico. Ambos informaram que usavam os rádios para trocar informações sobre a chegada da polícia. Ambos confirmaram o tráfico.

ISRAEL seria o olheiro e o adolescente, o vendedor. Com o adolescente foi apreendida a droga. ISRAEL se intitula no bairro como o "rei dos olheiros".

Trabalha há mais de um ano no local e recebeu essas informações no exercício de sua função.

LEANDRO SOUZA DUARTE - Policial Militar - narrou no mesmo sentido. Disse que

abordou o réu quando este tentou se esconder da viatura. Ele tinha um rádio comunicador. Outra viatura apreendeu um adolescente em poder de drogas e de outro rádios. Os aparelhos estavam na mesma frequência e se comunicavam. Ambos confirmaram os fatos e a comunicação entre si para o alerta da aproximação de policiais durante o tráfico de drogas.

JOSEANDRESON ALMEIDA CESAR JUNIOR – adolescente – nada disse na Delegacia de Polícia e não compareceu para ser ouvido em Juízo.

Interrogado, disse que “fazia isso” há dois dias apenas para usar droga. Estava em poder de dois rádios. Não conhecia o adolescente. Confirmou que disse aos policiais que tinha a função de olheiro. Ganhou R\$60,00. Não trabalhava para o adolescente. As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

O réu confirma ser olheiro de traficantes, mas tenta se desvincular do adolescente com quem as drogas foram apreendidas. Mas neste ponto entra as narrativas dos policiais, aliás participantes de abordagens distintas que se complementaram, coerentes e seguras. Cada qual tinha um rádio comunicador, ambos na mesma sintonia, no mesmo canal de comunicação.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: “A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada.” TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício.

Nesse sentido: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. “Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito -

Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido.” (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

DA PENA:

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 50-52): ISRAEL ESTANISLAU DE SOUZA SILVA JUNIOR ostenta maus antecedentes (0010421-40.2012.8.26.0451), Pena acima do mínimo legal.

Incide a causa de aumento (art. 40, inciso VI, Lei 11.343/06).

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Entendo não ser possível, também, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente. Imputa-se ao réu a prática de tráfico de drogas.

Narra a inicial acusatória que os policiais militares, em patrulhamento pela região, abordaram o denunciado com um rádio transmissor e um adolescente nas proximidades com drogas. O acusado confessou aos policiais que exercia a função de olheiro do tráfico.

O réu, perante a Autoridade Policial, disse que é viciado em crack e confessou que estava trabalhando como olheiro/radinho.

Em audiência judicial, a prova oral foi produzida e o réu interrogado.

Narraram os policiais militares, em apertadíssima síntese, que em patrulhamento na região dos fatos, lograram abordar o menor traficando e, em outra viatura, abordaram o réu com um radiotransmissor.

O réu, interrogado, disse que estava há poucos dias na função de olheiro para poder comprar drogas. Não avisou o adolescente. O rádio já estava desligado. Não trabalhava para o adolescente. Já estava indo embora para a sua casa. A absolvição é medida que se impõe. Nada há nos autos a comprovar a versão do policial de que o réu era conhecido como "o rei do rádio". Não há provas capazes a afirmar, estreme dúvidas, a dinâmica delitiva e a prática da conduta descrita na inicial.

Não se trata de considerar a versão do acusado alheia às provas dos autos, mas a constatação da inexistência de prova diversa daquelas que embasaram o starter investigativo.

Conceder peso menor à versão do acusado significa, em suma, atrair ônus probatório ao acusado, invertendo o estado de inocência (Por todos, Pacelli. 2020. P. 86 ; Aury Lopes, 2020, p. 143). Também o STF : " AS ACUSAÇÕES PENAIIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA . - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado." HC 88.875/AM Rel. Min. Celso de Mello.; em sentido similar, o E. TJSP: "Firme negativa por parte do acusado. Apelação provida para absolver o acusado por insuficiência de provas." (TJSP; Apelação nº. 1525685-32.2020.8.26.0228; Rel. Des. Amable Lopez Soto; 12ª Câmara de Direito Criminal; j. 15.12.2021).

Ante o alinhavado , desponta a absolvição ante a insuficiência do conjunto probatório o único desfecho possível.

Subsidiariamente, requeiro a desclassificação para a conduta do artigo 37 da Lei 11.343 de 2006.

Do apurado aos autos, deduz-se, no máximo, que o acusado exercia a função de informante da traficância, não havendo nenhuma colaboração causal com a efetiva transação ilícita de entorpecentes. Sequer há falar em contribuição estável e permanente naquele ponto de droga. Assim: "Admite-se a desclassificação para a capitulação jurídica nos termos do art. 37 da Lei de Drogas, à conduta de "olheiro", quando não demonstrada na origem a prática mediante contribuição estável e permanente aos destinatários das informações que possibilitariam o cometimento do tráfico de drogas, já que a referida figura típica pressupõe o vínculo esporádico e eventual". (AgRg no HC n. 632.550/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

Requeiro ainda aplicação do tráfico privilegiado, eis que o réu não se dedica à atividade criminosas e , apesar de já ter tido condenação, esta não tem ligação com o tráfico e é bem antiga. O tempo decorrido demonstra se tratar de traficante eventual. Requeiro seja fixada a pena no mínimo legal, anotando que a quantidade e diversidade de drogas não é anormal à espécie, bem como seja considerada a atenuante da confissão informal, em estrita obediência ao entendimento uniformizado pelo STJ sobre o tema por todos: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022, e tal atenuante deve compensar com eventual reincidência ("Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea." (AgRg no AREsp n. 2.021.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Aponto que não há relação da conduta do agente com o estado de pandemia declarado, razão pela qual tal agravante não deve incidir.

O regime inicial aberto é adequado ao caso em apreço.

Requeiro a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Inexistindo risco à produção probatório, eis que encerrada a instrução, nada havendo nos autos a indicar que o réu se furtaria à aplicação da lei penal, requeiro que seja concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ISRAEL ESTANISLAU DE SOUZA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de maio de 2022, por volta de 03h00, na Rua das Sapucaias, altura do n. 236, Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos com o adolescente J.A.C.J., trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 53 (cinquenta e três) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 10,6g (dez gramas e seis decigramas), e 33 (trinta e três) invólucros contendo "crack", substância derivada da cocaína, com peso líquido de 3,3g (três gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, surpreenderam o adolescente na posse de uma pochete e viram que ele, ao perceber a viatura, empreendeu fuga para uma mata. Após perseguição, detiveram-no e apreenderam em poder dele as drogas acima descritas, dinheiro (R\$ 66,00) e um rádio comunicador.

Nas proximidades, por outra viatura, foi detido o réu, o qual portava um rádio comunicador idêntico ao apreendido com o menor.

Aos policiais, o réu confessou que exercia a função de olheiro, avisando o adolescente sobre a aproximação de viaturas policiais. O menor também confirmou aos milicianos a prática do comércio de drogas e que recebia informações do réu.

Assim, é certo que ambos, agindo de comum acordo, realizavam, com funções distintas, o tráfico ilícito de entorpecentes.

Na delegacia, o réu e o adolescente ficaram em silêncio.

A denúncia foi oferecida (fls. 84), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 88/89).

Notificado (fls. 95), o réu apresentou defesa prévia, na qual alegou requereu a concessão da liberdade provisória (fls. 99/102).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls.111/114). O réu foi citado (fls. 137).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, na fotografia de fls. 17, no laudo de constatação de fls. 20/22, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 76/78, segundo o qual foi detectada cocaína nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu disse que é usuário de crack e recebe R\$ 60,00 para ser "olheiro" de um ponto de venda de drogas, das 21h00 às 04h00. Fica com o rádio comunicador e tenta informar sobre a chegada de policiais no local. É olheiro de outro ponto de venda de drogas e não daquele em que o menor infrator estava vendendo (fls. 06).

Em Juízo, o réu afirmou que fazia "isso", para consumir drogas. Estava na posse dos dois rádios comunicadores. Só soube que o adolescente tinha sido abordado na Delegacia. Não o conhecia. Falou aos policiais, com medo de apanhar, que estava há 02 ou 3 dias trabalhando como "olheiro", para usar crack. Ganhava R\$ 60,00 pelo dia de serviço. Não trabalhava para o adolescente. Não avisou o adolescente que a viatura estava chegando. Já tinha sido dispensado e estava indo embora, quando foi abordado com uma conhecida. Trabalhava das 21h00 até às 4h00. Usa crack, maconha e cocaína e não conseguia ficar sem consumi-la.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial militar Eduardo de Carvalho Oliveira afirmou que estavam em patrulhamento, quando adentraram à rua das Sapucaias, onde fica o "trio", trilha que liga um bairro a outro e local onde se vende a droga. o adolescente vinha subindo a rua e, quando viu a viatura, tomou direção contrária e correu para o

mato, onde fica o “trio”. Dava para ver que ele segurava alguma coisa em ambas as mãos. Desembarcou, acompanhou o adolescente, até que ele se deparou com uma cerca de arame e conseguiu abordá-lo. Em uma das mãos, ele tinha uma pochete, na qual havia drogas (maconha, cocaína e crack) e dinheiro. Na outra mão, ele segurava um rádio comunicador. Voltou com o adolescente na rua e o algemou, em razão da fuga. Colocaram o adolescente e na viatura, andaram um pouco e encontraram outra viatura, do Sargento Duarte. O sargento estava abordando uma outra pessoa, o réu, que tinha um rádio comunicador idêntico aquele que estava na mão do adolescente.

Informalmente, o adolescente e o réu contaram que o rádio era para avisar quando chegava a viatura. Assim, o adolescente fazia a venda e o réu era o “olheiro”. No local e na Delegacia, testaram e constatou-se que os aparelhos se comunicavam na mesma frequência. Teve pouco contato com o réu, mas eles informaram que o adolescente vendia e o réu era o “olheiro”. O réu é conhecido no bairro como o “rei dos olheiros”, por meio dos policiais. Nunca tinha abordado o réu.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Leandro Souza Duarte, segundo o qual estavam em patrulhamento, em local conhecido como venda de drogas e determinou que uma viatura descesse a rua das Sapucaias e outra fosse pela rua paralela e adentrou na rua das Sapucaias, em sentido contrário. Quando ingressou na rua das Sapucaias, já visualizou o réu próximo ao campo de futebol, agachado, tentando se esconder e, por isso, realizou a abordagem. Com o réu, havia um rádio comunicador. O réu falou que trabalhava como “olheiro”, das 15h00 às 4h00 e ganhava R\$ 60,00 por dia. Ele falou que já tinha avisado a chegada da outra viatura. A outra viatura avisou que tinha abordado o adolescente com drogas e com um rádio comunicador. Os dois rádios estavam na mesma frequência. Não conhecia o réu. Informalmente, o adolescente confessou que estava na prática do tráfico de drogas. Não conhecia o réu.

O adolescente J.A.C.J. nada mencionou na fase policial (fls. 05) e, em oitiva informal, nos autos nº 1500691-20.2022.8.26.0599, que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude local, confessou a prática do tráfico de drogas, disse que foi perseguido e capturado pelos policiais, na posse de crack e cocaína (fls. 33), sendo-lhe aplicada remissão com medida socioeducativa de liberdade assistida. A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Em solo policial, o réu confirmou que trabalhava como “olheiro”, avisando os traficantes sobre a aproximação de policiais. Negou, contudo, que trabalhasse para o adolescente que foi preso, naquele dia. Judicialmente, o réu aduziu que estava na função de “olheiro”, no entanto, já tinha acabado seu turno e, quando foi abordado, estava na posse dos dois rádios comunicadores. Negou relação com o adolescente apreendido.

Os policiais militares esclareceram que Eduardo estava em patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas e avistou o adolescente caminhando pela via, com uma pochete. Ao avistar a viatura, o adolescente empregou fuga em direção a uma área de mata, sendo capturado em seguida. Na posse dele, foram localizadas 53 porções de cocaína, 33 porções de crack, além de dinheiro e um rádio comunicador. A equipe do policial Leandro estava em direção oposta, na tentativa de realizar o cerco e ingressou na mesma via, em sentido oposto, quando visualizou o réu, próximo de um campo de futebol, tentando se esconder. Ele foi abordado e, com ele, em revista pessoal, localizaram um rádio comunicador idêntico àquele que foi apreendido com o adolescente. Informalmente, o réu confessou que receberia R\$ 60,00 para exercer a função de “olheiro”, ou seja, para passar informações sobre a aproximação de viaturas policiais ao adolescente, trabalhando nessa atividade das 21h00 às 04h00. Os policiais informaram que foi realizado o teste dos rádios e eles estavam na mesma frequência.

Num primeiro momento, devemos verificar se o réu estava envolvido com a droga apreendida.

Existem duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, no sentido de que não estava auxiliando o adolescente na venda da droga, e a dos policiais militares, no sentido de que o adolescente foi abordado com a droga apreendida, mas ele tinha o auxílio do réu, para avisá-lo, por meio de radiotransmissores, que eles carregavam consigo.

Nesses termos, considerando que o adolescente foi apreendido com drogas e tinha consigo o radiotransmissor idêntico ao do réu e na mesma frequência que o dele, entendo que a prova é suficiente para a certeza e o réu que auxiliava o adolescente no comércio espúrio de drogas.

Note-se que o réu disse que trabalhava até às 4h00, no entanto, a abordagem ocorreu às 3h00, ou seja, antes de seu turno de serviço ter terminado, de forma que fica claro que ele ainda estava exercendo o trabalho de "olheiro", quando foi abordado. De mais a mais, os rádios comunicadores estava, segundo os policiais, um com o adolescente e outro com o réu, confirmando a ajuda do réu ao vendedor de drogas. Assim, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos policiais militares que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes policiais tem validade como prova, em especial quando confirmada pela apreensão das drogas e dos rádios comunicadores.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Comprovada o envolvimento do réu com a droga apreendida com o adolescente, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

O réu negou relacionamento com o adolescente ou com a droga apreendida. A prova confirma, contudo, que a destinação da droga era o consumo de terceiras pessoas. Inicialmente, policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o adolescente

andando pela via com uma pochete e, ao avistar a viatura, ele empregou fuga para uma área de mata, sendo capturado em seguida. Com ele encontraram 53 porções de cocaína e 33 porções de crack, além de dinheiro em espécie, em notas trocadas, confirmando que a única destinação era o consumo de terceiras pessoas. Com o adolescente, também havia um radiotransmissor.

Em outra viatura policial que ingressou na mesma via, em sentido oposto, avistou o réu se escondendo e efetuaram sua abordagem. Com o réu, havia outro rádio comunicador, idêntico àquele que estava com o adolescente.

Assim, restou claro que o adolescente estava na prática da mercancia ilícita de drogas e o fazia com a ajuda do réu, que era incumbido de avisá-lo da aproximação da viatura policial, impedindo que ele fosse apreendido.

A ação do réu, portanto, auxiliava o comércio espúrio de drogas e era necessário à tranquilidade do vendedor.

Note-se que o réu, confessou que exercia esse função, embora tenha falado que não trabalhava para o adolescente, ganhando R\$ 60,00 para passar informações sobre a aproximação de viaturas policiais, fazendo um turno de trabalho das 21h00 às 04h00. Assim, mesmo que o réu não tenha sido abordado na posse de entorpecentes, é certo que estava concorrendo para a traficância, ao passar informações sobre as viaturas policiais, de maneira a evitar a abordagem policial.

Nesse contexto, a atitude do réu, a droga encontrada com o adolescente, a quantidade, sua forma de embalagem; tudo revela que a droga apreendida tinha como destinação a mercancia ilícita.

Ressalto que, ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal -Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, portanto, se impõe, não cabendo qualquer desclassificação pretendida, porque o réu não trabalhava como informante, mas sim fazia atuação conjunta com o

adolescente que vendia a droga aos usuários, tornando a atividade deste mais fácil e de menor risco e impedindo que a droga fosse apreendida pelos policiais. Agia como coautor e não como colaborador.

3) Da causa de aumento de pena

A pena do réu deve ser aumentada, uma vez que se utilizava também do adolescente J. para a prática do delito.

O próprio adolescente afirmou, à autoridade policial, que estava traficando, sendo que o réu o avisava sobre a proximidade das viaturas policiais, concorrendo para o delito.

A conduta do réu, agindo com o adolescente para a prática do tráfico, reveste-se de maior reprovação, uma vez que acaba por influir negativamente na má formação do adolescente.

Resta saber se o adolescente foi devidamente qualificado, para que seja possível a caracterização do delito.

É que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: Tema nº 1052 - Qualificação - Menor - BO - Documento - "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."

No caso em tela, quando o adolescente foi levado à Delegacia de Polícia, foi lavrado o boletim de ocorrência e ele foi devidamente qualificado, exibindo a cédula de identidade aos policiais, consoante extrato de qualificação das partes (fls. 13) e o próprio documento de fls. 24.

Assim, cumpridas as exigências jurisprudenciais, é possível o reconhecimento da causa de aumento de pena.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu possui antecedente criminal (Certidão de fls. 50 - Processo nº 0010421-40.2012.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Não há possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, porque embora o réu tenha mencionado que exercia a função de "olheiro", negou que o fizesse com relação ao adolescente, de forma que, negou o crime aqui tratado.

A causa de aumento fará incidir acréscimo de um sexto: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não é cabível diante dos maus antecedentes do réu.

Não há outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos e o réu é portador de antecedentes criminais.

Pena final: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ISRAEL ESTANISLAU DE SOUZA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada.

O réu está preso e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser gravíssimo, está intranquilizando a sociedade, porque contribui para a má formação dos jovens desta comunidade e fomenta a prática de outros delitos graves, contra o patrimônio e a vida. Ademais,

o estado civil e a condição profissional do réu no momento da prisão (solteiro - fls. 06; aposentado - fls. 06) não o prendem ao distrito da culpa. No caso concreto, ademais, o réu demonstrou sua periculosidade utilizar-se do adolescente para o tráfico, trazendo grande repercussão social. Assim, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. Deixo de decretar o perdimento do dinheiro, uma vez que apreendido na posse do adolescente e não do réu.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, servindo-se esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o(a)(s) réu(é)(s) manifestou(ram) desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s), devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):